

刑法
No306

共通問題 R7-4

(配点: 2)

月 日

月 日

学生A及びBは、【会話】のとおり議論している。【会話】中の①から⑧までの()内に【語句群】から適切なものを入れた場合、正しいものの組合せは1から5までのうちどれか。なお、①から⑧までの()内には、それぞれ異なるものが入る。

【会 話】

学生A. 支払意思・能力がないことを秘して飲食店で注文し、飲食物の提供を受けた無銭飲食の事案について、詐欺罪は成立しますか。

学生B. 私は、判例と同様に、(①)といえ、(②)に当たるので、詐欺罪が成立すると考えます。

学生A. 約款により暴力団関係者の施設利用を拒絶しているゴルフ場において、暴力団関係者がその旨を申告することなく施設利用をした場合はどう考えますか。

学生B. 私は、判例と同様に、事案によっては詐欺罪が成立しない場合もあると考えます。詐欺罪が成立するとした判例では、(②)を認定できる事情がありました。一方、詐欺罪が成立しないとした判例では、ゴルフ場側が(③)するなどして、暴力団関係者による施設利用を(④)する意向を示していたものの、それ以上に(⑤)する措置は講じていなかったという事情がありました。また、(③)している周辺のゴルフ場において、暴力団関係者の施設利用を(⑥)する例が多数あったことなど、(②)を認定することが困難な事情がありました。そのため、暴力団関係者であることを申告せずに施設利用を申し込んだとしても、(⑦)ので、(⑧)としました。

【語句群】

- a. 飲食後、直ちに代金を支払う意思・能力がないことを告知する義務があるのに、その義務に違反して真実を告げていない
- b. 飲食店における注文は、暗黙の前提として、飲食後、直ちに代金を支払う意思・能力があるとの意思表示を内包している
- c. 挙動による欺罔行為
- d. 不作為による欺罔行為
- e. 利用客に対して暴力団関係者でないことを確認
- f. 暴力団関係者の施設利用を拒絶する旨の立看板を設置
- g. 許可・黙認
- h. 拒絶
- i. 利用客は正規の利用料金を支払っており、ゴルフ場に経済的な不利益はない
- j. 申込者が当然に暴力団関係者でないことまで表しているとは認められない
- k. 財産的損害が発生していない
- l. 欺罔行為に当たらない

1. ① a ③ e ⑤ f ⑦ i
2. ① b ④ g ⑥ h ⑦ j
3. ② c ④ h ⑥ g ⑧ l
4. ② d ⑤ f ⑥ h ⑧ k
5. ③ f ⑤ e ⑦ i ⑧ k

No306

共通R7-4

詐欺罪における欺罔行為

正解

3

正答率

83%

() には順に、「① = b、② = c、③ = f、④ = h、⑤ = e、⑥ = g、⑦ = j、⑧ = l」と入り、したがって、正解は肢3となる。

①、②について

大判大9.5.8は、無銭飲食等の事案で、料理店において飲食をする際には、飲食代金を支払うことが取引上の一般慣例であり、そこでの飲食の注文は代金の支払いという暗黙の意思表示を包含するものであるとして、欺罔行為の成立を認めている。このように行為者の言動が黙示的に虚偽の事実を表示していると評価できる場合は、挙動による欺罔行為と呼ばれている。よって、①には「b. 飲食店における注文は、暗黙の前提として、飲食後、直ちに代金を支払う意思・能力があるとの意思表示を内包している」が入り、②には「c. 挙動による欺罔行為」が入る。

③、④、⑤、⑥、⑦、⑧について

約款により、暴力団関係者の施設利用を拒絶しているゴルフ場において、暴力団関係者がその旨を申告することなく施設利用をした事案で、詐欺罪が成立するとした判例は、最決平26.3.28である。他方、詐欺罪が成立しないとされた判例は、最判平26.3.28（百選Ⅱ51事件）である。後者の事案では、暴力団関係者の施設利用を拒絶する旨の立看板を設置し、暴力団関係者による施設利用を拒絶する意向を示していたものの、その一方で受付表に暴力団関係者か否かを確認する欄を設けるなどの、利用客に対して暴力団関係者でないことを確認する措置を講じていなかった。よって、③には「f. 暴力団関係者の施設利用を拒絶する旨の立看板を設置」が入り、④には「h. 拒絶」が入り、⑤には「e. 利用客に対して暴力団関係者でないことを確認」が入る。また、この事案では、問題となったゴルフ場と同様に暴力団関係者の施設利用を拒絶する旨の立看板等を設置している周辺のゴルフ場において暴力団関係者の施設利用を許可、黙認する例が多数あった。以上のような事情を考慮して、同判例は、「施設利用を申し込む行為自体は……申込者が当然に暴力団関係者でないことまで表しているとは認められない。そうすると……本件各ゴルフ場の各施設利用申込み行為は、詐欺罪にいう人を欺く行為には当たらない」としている。よって、⑥には「g. 許可・黙認」が入り、⑦には「j. 申込者が当然に暴力団関係者でないことまで表しているとは認められない」が入り、⑧には「l. 欺罔行為に当たらない」が入る。